

1500138-68.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500138-68.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500138-68.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2018371/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 15786453 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

182/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2018371 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 182/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS GUSTAVO PEREIRA DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

LUÍS GUSTAVO PEREIRA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso inquérito policial, lavrado em decorrência de auto de prisão em flagrante que, na data de 20 de janeiro de 2021, por volta das 18h30min, na Avenida Prefeito Ary Levi Pereira, nº 1586, Parque Residencial Belinha Ometto, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, o acusado adquiriu e trazia consigo, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 189 porções de Cocaína, pesando 24,45g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, o acusado recebeu considerável quantidade de cocaína para desenvolver o comércio ilícito de drogas nos bairros Belinha Ometto e imediações. Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na Rua Avenida Prefeito Ary Levi Pereira, conhecido como ponto de tráfico ilícito de

drogas, quando avistaram LUÍS GUSTAVO em uma bicicleta, no contrafluxo de direção.

Ao perceber a aproximação da viatura, o réu demonstrou nervosismo e passou a pedalar rapidamente. Após alguns metros, os agentes públicos abordaram LUÍS GUSTAVO e, durante revista pessoal, encontraram nas vestes dele sete kits contendo 189 microenvelopes preenchidos com cocaína.

Em continuidade à diligência, os policiais militares dirigiram-se a moradia do réu, nas imediações da instituição de ensino superior "Unicamp" (Universidade de Campinas), onde encontraram e apreenderam um caderno contendo contabilidade do tráfico ilícito de drogas, dentro do guarda-roupas de LUÍS GUSTAVO. Seguidamente, os agentes públicos ali também encontraram e apreenderam R\$3.452,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) em cédulas diversas, uma balança de precisão e diversos microenvelopes da marca Zip Lock.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 139/148).

A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2021 (fls. 156/159).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 211/218) e da Defesa (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analiso as preliminares levantadas pela Defesa.

Não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar.

Como se sabe, a inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia.

A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. Assim, o contexto de flagrante delito e o estado de necessidade de terceiros (socorro ou desastre) prescindiriam do consentimento expresso do morador.

A configuração do flagrante delito, como se sabe, é uma das hipóteses autorizadoras do ingresso no domicílio alheio. Aqui, no conflito emergente entre a privacidade e o resguardo imediato da ordem pública, o legislador inclinou-se em favor do último.

Assim, da hipótese daquele que é surpreendido no momento em que comete a prática delituosa ou que acaba de cometê-la (flagrante próprio), àquele que é encontrado logo depois, em poder dos objetos ou instrumentos do delito (flagrante presumido), passando pela situação de perseguição imediata e ininterrupta (flagrante impróprio), conferiu o legislador mandamento aos agentes públicos para efetivarem a prisão, independentemente de ordem judicial (art. 302 do CPP).

Ora, se a custódia em tais casos é executada diretamente, natural que o ingresso no domicílio também possa se dar diretamente até mesmo para a concretização daquela prisão.

Então, não houve violação de domicílio, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Não bastasse, cabe ainda chamar a atenção que, no caso concreto, havia fundadas suspeitas da prática de crime do tráfico no local a autorizar a ação da polícia militar.

De fato, revelou a prova oral que a diligência policial questionada pela Defesa foi precedida de abordagem prévia suspeita em via pública. Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas, quando avistaram o acusado em uma bicicleta, no contrafluxo de direção.

Ao perceber a presença e aproximação da viatura, o réu demonstrou nervosismo e passou a pedalar rapidamente. Após alguns metros, os agentes públicos o abordaram e, durante revista pessoal, encontraram nas vestes kits contendo 189 microenvelopes preenchidos com cocaína.

Em razão desses fatos, houve buscas no interior da residência e os agentes públicos apreenderam um caderno contendo contabilidade do tráfico ilícito de drogas, dentro do guarda-roupas do acusado. Em seguida, também encontraram e apreenderam R\$3.452,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) em cédulas diversas, uma balança de precisão e diversos microenvelopes da marca Zip Lock.

Em resumo, o réu estava em comportamento típico de tráfico, mas foi interrompido pela ação da polícia militar, havendo prisão em flagrante.

Os elementos trazidos pelos policiais militares corroboraram a fundada suspeita da ocorrência de crime de tráfico não só na via pública mas também no imóvel residencial do denunciado, com o encontro de apetrechos, acessórios e produto da traficância, de crime considerado permanente, o que justificou a busca e apreensão sem mandado judicial.

Havendo, portanto, sérios e concretos indicativos da prática de tráfico no local dos fatos, não há que se falar em afronta à tese firmada em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário 603.616 do Colendo Supremo Tribunal Federal (tema 280):

“Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Não é outro o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, a saber:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CRIME – FLAGRANTE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, surge lícita a entrada forçada em domicílio sem prévia autorização judicial”. (STF, HC 177923, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 03-03-2021 PUBLIC 04-03-2021).

"Agravamento regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crime de tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Exceção. Situação de flagrante delito. Controvérsia acerca do ingresso de policiais no domicílio (...). 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (RE nº 603.616-AgR/RG – Tema 280). 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via processual do habeas corpus. Precedentes. (...) 5. Agravamento regimental não provido". (STF, HC 197268 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. (...) INVOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares. 3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes. 4. Agravamento regimental desprovido". (STF, ARE 1312140 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

"Penal e processual penal. Agravamento regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, com fundamento nas provas produzidas e submetidas ao contraditório, reconheceram a inexistência de entrada forçada no domicílio do recorrente, identificando a prévia justa causa para o ingresso por parte dos policiais (...). 4. Agravamento regimental a que se nega provimento". (STF, HC 198582 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021).

Também não pode ser acolhida a tese da Defesa consistente na quebra da cadeia de custódia com o consequente desentranhamento de todas as provas colhidas.

O instituto inserido no art. 158-A do Código de Processo Penal é definido por Renato Brasileiro como "mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração. Funciona, pois, como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória, assegurando, assim, o rastreamento da evidência desde o local do crime até o Tribunal" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020).

De acordo com a narrativa dos policiais militares, todos os objetos apreendidos quando da prisão em flagrante, de interesse da investigação criminal, foram devidamente encaminhados à Autoridade Policial, que os discriminou em auto de exibição e apreensão.

Não bastasse, não houve insistência na produção de qualquer prova pericial em audiência, nem tampouco após o encerramento da instrução (art. 402, do CPP).

Ainda que assim não fosse, eventual quebra da cadeia de custódia aduzida pela Defesa não tem o condão de invalidar todo o conjunto probatório, uma vez que a prova testemunhal consistente na oitiva de policiais militares confirma a dinâmica dos fatos criminosos, tal como descrito na denúncia, conforme se verá a seguir, não havendo que se falar, portanto, em ausência de segurança quanto ao manuseio da balança, dinheiro, caderno de anotações, drogas e demais apetrechos apreendidos, com indevida alteração da autenticidade das evidências.

Desta forma, o procedimento ditado pela legislação processual penal acerca da documentação e preservação da prova produzida foi observado e, com o devido respeito, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 158-A, do Código de Processo Penal, muito menos em falta de materialidade delitiva.

Não há outras preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), laudo pericial com resultado positivo para cocaína (fls. 20/22 e 99/101), bem como a prova oral colhida.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado, acompanhado de defensor constituído, disse que estava com sua bicicleta indo buscar droga na Serra, ou seja, no Parque Nossa Senhora das Dores, pois é usuário de cocaína. Em determinado momento, foi abordado pelos policiais militares, que não encontraram nada consigo, negando que estivesse na posse de qualquer droga. Quando os policiais chegaram, indivíduos que acredita trabalharem na biqueira saíram correndo, tendo os policiais militares perguntado para o interrogando se os conhecia, tendo negado. Os policiais militares questionaram sobre o seu RG, tendo-o levado até a casa da sua mãe, pois acreditava que lá o documento estava. Sua mãe disse aos policiais que o seu RG devia estar onde ele estava residindo, indicando, inclusive, o endereço no bairro Cidade Universitária. Chegando lá, os policiais perguntaram onde o RG estava, tendo falado que estava dentro de um tênis no interior da residência. Ela abriu o portão para que os policiais entrassem, embora não tenha aberto a porta do apartamento, sendo certo que os militares entraram enquanto mantinham ele com um dos policiais do lado de fora. Os policiais militares voltaram dizendo que encontraram as embalagens vazias. Afirma que desconhece a existência desse material no interior do apartamento, não sabendo de onde saiu. Disse que não é traficante, apenas usuário. Em nenhum momento franqueou a entrada dos policiais em seu apartamento (fls. 06).

Em Juízo, o réu disse que tem 21 anos. Está trabalhando como autônomo com seu padraço. É amasiado. Foi no local da prisão para comprar drogas. Os moleques saíram correndo. Foi enquadrado pelos guardas. Eles passaram a procurar e acharam drogas numa árvore. Falou onde morava e foi no Geada com os guardas. Só estava seu irmão na casa dos seus genitores. No imóvel que residia estava o RG e lá os guardas entraram, mas ele ficou dentro da viatura quando os policiais estavam no apartamento. Morava na quitinete. Os policiais foram primeiro na casa dos pais dele. Conseguiu comprar duas porções, só tinha isso em seu poder quando da

abordagem. Estava de bicicleta, não tentou fugir, foi tudo muito rápido. É usuário e foi comprar dois pinos. Conhecia os guardas de vista, mas nunca tomou enquadros deles. Quando era menor de idade, teve passagem por tráfico e ficou internado por nove meses, foram duas internações seguidas. Falou aos guardas que o seu documento estava dentro do guarda-roupa. Nada sabe a respeito do encontro do caderno, da balança de precisão e do dinheiro até porque ficou dentro da viatura, do lado de fora. Não autorizou a entrada dos policiais no apartamento (mídia).

Sua versão não convence e cede ante o conjunto probatório colhido.

Vejam os teores da prova oral, contrária aos interesses do réu.

O policial militar Ivan Dias de Jesus contou que, na data dos fatos, estava com o policial Allan, em adjacências de ponto de tráfico, na Avenida Prefeito Ary Levi. Viram o réu numa bicicleta, no contrafluxo de direção. Quando passaram, o denunciado demonstrou nervosismo e passou a olhar para trás pedalando mais rapidamente. Foram no encalço do acusado. A cerca de trezentos metros, o acusado tentou ir para a guia, mas foi abordado. Em busca pessoal seu colega encontrou na cueca do acusado 7 kits de microenvelopes contendo cocaína, no total de 189 porções. Indagado, ele passou a ficar nervoso em se identificar. O acusado indicou que morava no bairro Geada, perto do local da abordagem. Foram até o local indicado. Quando chegaram na casa viram que era a residência da genitora. Foi informado que ali ele não morava e que o denunciado morava em outro local. O acusado disse que mentiu aos guardas, pois realmente morava no bairro universitário e que lá no seu apartamento teria dinheiro e balança. Foram até o endereço indicado e lá chegando o acusado abriu o portão, indicando onde estava a documentação e os objetos. Abriu o guarda-roupas e achou a identidade, assim como dinheiro em notas diversas. Havia um caderno com anotações do tráfico, assim como uma sacola com vários envelopes. O acusado morava sozinho. Deram voz de prisão. Foi o próprio acusado quem falou onde estava a documentação. Os parentes do imputado presenciaram o deslocamento da viatura. Ali perto do apartamento há o campus de uma faculdade. Não se recorda de outras abordagens envolvendo o acusado. A entrada da guarnição foi autorizada, foi o acusado quem indicou onde estava o documento e o dinheiro proveniente de tráfico, que era sustento da família. A quantidade de dinheiro não era pouca, encontraram perto de três mil e pouco reais. Em alguns dos saquinhos havia a figura de desenhos. Havia embalagens vazias que foram encontradas. A autorização do acusado foi verbal, ele acompanhou toda a diligência policial. Não se recorda se o portão estava trancado, toda vistoria foi acompanhada pelo réu. Fizeram vistoria apenas no local indicado pelo denunciado. A residência dele é uma quitinete, o local é cercado por um portão de entrada e depois ingressa no imóvel, há um portão vazado com frestas. Não sabe ao certo se o portão estava aberto, o réu fez a abertura. Todo material foi apreendido e entregue à autoridade policial. Não se recorda se tiraram fotografias. O local da abordagem é perto de uma biqueira, há um ponto de tráfico um pouco mais à frente (mídia).

O policial militar Allan Danilo de Souza Oliveira contou que faziam patrulhamento quando viram o acusado de bicicleta, no contrafluxo do sentido, havendo demonstração de nervosismo ao ver a viatura policial. Conseguiram aborda-lo. Em revista pessoal localizaram 189 porções de cocaína. Indagado, ele disse que iria levar as drogas até uma biqueira. Ele não tinha identificação e deu mais de um nome durante a abordagem. O réu contou que morava no bairro Geada e foram até o endereço dos familiares, os quais informaram que ali ele não morava. Nesse momento, o acusado disse que mentiu aos guardas e que no seu apartamento havia dinheiro e petrechos de tráfico. O acusado franqueou a entrada aos policiais e indicou onde estavam os itens formados. Encontraram caderno de contabilidade e muito dinheiro. Deram voz de prisão. Foi um dos familiares que os recebeu e depois chegaram mais familiares. No deslocamento do bairro Geada até a cidade universitária os familiares foram em outro veículo. O acusado indicou onde estavam os pertences. Tudo foi entregue ao delegado. A entrada foi franqueada. Quem abriu o portão foi a

esposa do acusado, o réu estava algemado (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais militares, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Defesa.

A testemunha Ana Maria de Souza disse que é tia do réu. Foi ouvida como informante. A sua cunhada pediu pra ir olhar as filhas mais novas. Na hora que chegou a viatura estava defronte à residência, viu que o portão estava aberto. Sua cunhada é a Valéria. O acusado saiu algemado e os policiais falaram que iriam no bairro próximo para pegar a documentação. Seguiram a viatura policial até a casa do réu. A polícia entrou para pegar o documento e o réu ficou do lado de fora. Valéria é mãe do denunciado. Sabe que os policiais entraram na casa dela e depois foram na casa do imputado pegar o documento pessoal (mídia).

A testemunha Valéria Pereira e Almeida disse que é mãe do réu. Foi ouvida como informante. Tinha acabado de sair de casa e não presenciou a prisão. Deixou seu filho menor em casa. A vizinha avisou que a polícia ingressou na sua casa. A viatura já estava saindo com o acusado, ele não morava mais com ela. Só o filho de treze anos estava na sua casa. Seguiu a viatura para ver onde os policiais iriam com o réu. Os policiais foram até o apartamento do seu filho. Os militares ingressaram no apartamento e os familiares ficaram do lado de fora. Os guardas saíram e pediram pra todo mundo ir até a delegacia (mídia).

Pois bem.

De acordo com a prova oral colhida, policiais militares faziam patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, quando viram o acusado em uma bicicleta no contrafluxo de direção. Ao notar a aproximação da viatura, o réu passou a pedalar rapidamente e demonstrou nervosismo, sendo abordado pelos agentes públicos.

Durante a revista pessoal, os guardas encontraram nas vestes do acusado sete kits contendo 189 microenvelopes preenchidos com cocaína. Em continuidade à diligência, os policiais militares foram até a moradia do réu, nas imediações da Unicamp, onde

encontraram e apreenderam um caderno contendo contabilidade do tráfico, dentro do guarda-roupas do acusado.

Também foram apreendidos R\$3.452,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) em cédulas, uma balança de precisão e diversos microenvelopes da marca Zip Lock.

Assim, respeitado o entendimento da combativa Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), as circunstâncias da prisão em flagrante, o local da abordagem, a posse de grande quantia em dinheiro, o encontro de balança de precisão, embalagens vazias e manuscritos relacionados à traficância, com depoimento incriminador dos agentes públicos, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Ausência de visualização de atos de mercancia – Irrelevância – Tipo misto ou de conteúdo variado – Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

E não há que se falar em desclassificação do delito imputado para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (189 porções de cocaína escondidas na cueca), assim como as circunstâncias da prisão, com depoimento incriminador dos policiais militares quanto ao crime de tráfico de drogas.

Em conformidade com os ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim já decidiu:

"Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância. (...)" (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Por outro lado, não foram arroladas testemunhas de Defesa (com exceção da genitora e tia do réu, ambas ouvidas na condição de informante) que corroborassem a versão do imputado de não ter qualquer envolvimento com a traficância ilícita, devendo prevalecer o relato dos policiais militares que efetuaram a abordagem e o prenderam em flagrante delito.

No mais, chama a atenção a divergência de versões apresentadas pelo acusado quando interrogado na Delegacia e em Juízo, de atos procedimentais que sempre tiveram a presença de defensor constituído (cf. fls. 06).

Em solo policial, o réu contou que franqueou a entrada de policiais militares no prédio onde residia, mas não em seu apartamento, não havendo qualquer menção de arrombamento. Na fase do contraditório, todavia, ele afirmou que não deu qualquer autorização para ingressar no seu imóvel, o que certamente leva à conclusão de que os militares ingressaram de forma forçada, com evidente afronta à lei, o que não se sustenta quando confrontado com o relato dos policiais.

Também não houve qualquer explicação acerca do encontro de mais de três mil reais em seu apartamento, assim como do caderno de anotações de venda de drogas e da balança, com a singela alegação de que desconhece os apetrechos apreendidos pelos

agentes públicos.

É inquestionável que a ação da polícia militar se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal ou domiciliar.

Durante o patrulhamento ostensivo e preventivo, o acusado foi abordado em decorrência de comportamento suspeito, por demonstrar nervosismo ao presenciar a viatura policial e tentar evitar a aproximação dos militares (tentativa de fuga), em local conhecido pela traficância ilícita. Havia em seu poder 189 porções de cocaína, circunstâncias que somadas geraram a fundada suspeita da posse de objetos ou substâncias ilícitas, que, por sua vez, autorizaram a busca em conformidade com os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.

Nessa direção, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. (...)
1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (...)" 6. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Hipótese em que o Tribunal de origem, diante das circunstâncias peculiares do caso - veículo parado em atitude suspeita, durante a madrugada, com quatro indivíduos em seu interior - entendeu haver fundada suspeita para a realização da abordagem pessoal, que resultou na apreensão de arma de fogo. A decisão vergastada está em consonância com o art. 244 do CPP e os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido são legítimos para fins de busca pessoal. Rever a conclusão do aresto necessitaria do reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019).

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são favoráveis ao réu, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula n. 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase, observo que o réu possui antecedentes por atos infracionais quando da sua menoridade (fls. 36 e 205/206), tendo cumprido medidas socioeducativas de internação por tráfico nos processos nº 0000317-81.2018.8.26.0320 e 1500215-68.2018.8.26.0551, fato assumido pelo acusado quando interrogado, o que denota dedicação à atividade criminosa quando somados com o encontro de 189 porções de cocaína, R\$3.452,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) em dinheiro (sem qualquer justificação), uma balança de precisão, caderno de anotações contendo anotações de venda de drogas e diversos microenvelopes da marca Zip Lock, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, na linha da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (STJ, AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos, assim como pelo fato de que o paciente já respondeu por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas (...) Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 604.121/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020).

"(...) - O ora paciente conta com condenação anterior à medida socioeducativa de internação, pela prática do ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes. Dessa forma, sobeja essa razão, idônea nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, para afastar a redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois atesta a dedicação do acusado à atividade criminosa (...) Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 481.232/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Apesar da Defesa afirmar que o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a utilização de atos infracionais não constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado, a questão não é pacífica e encontra divergência no âmbito das duas turmas da Suprema Corte, em conformidade com os julgados que cito abaixo:

"Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF, HC 192147 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021).

"Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF, RHC 190434 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 12-11-2021 PUBLIC 16-11-2021).

"Habeas corpus. (...) Redutor. Tráfico privilegiado. Existência de ato infracional. (...) 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, "[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006" (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). (...) (STF, HC 195540, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021).

No mesmo sentido, confira-se: STF, HC 206922, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 24/09/2021, publicado em 27/09/2021.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão (189 porções de cocaína, pesando 24,45 gramas), nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional das penas em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LUÍS GUSTAVO PEREIRA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como respondeu solto e compareceu aos atos processuais, poderá recorrer desta em liberdade.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido e demais objetos, porquanto fruto do tráfico.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA